

1501970-73.2020.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... denúncias sobre ele e seu envolvimento com o tráfico. No momento da abordagem, ele estava parado, sozinho. O local é conhecido como ponto de tráfico e várias prisões já foram realizadas ali. No momento, o réu alegou que os R\$ 30,00 (trinta reais) eram provenientes da venda de drogas e que havia três pedras em sua casa e que o restante já havia sido vendido. No interior da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

3ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, . - Vila Affine

CEP: 19700-000 - Paraguacu Paulista - SP

Telefone: (18)3361-2844 - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

1501970-73.2020.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501970-73.2020.8.26.0417

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VICTOR GAVAZZI CESAR

Vistos.

NATAN GOMES DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na madrugada de 11 de dezembro de 2020, por volta das 00h10min, na rua Joaquim Clemente nº 28, neste município e comarca de Paraguaçu Paulista, teria guardado e mantido em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1,39g de cocaína, na forma de 16 pedras de crack, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo de constatação provisória (fls. 28/30) e definitivo da droga (fls. 68/70).

Após o oferecimento da denúncia, o réu foi devidamente notificado (fls. 98) e apresentou defesa prévia (fls. 112/119).

Após o recebimento da denúncia (fls. 125/126), por não se vislumbrar qualquer hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu procedência da pretensão

acusatória, com condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu, apontando para a fragilidade do acervo probatório, decorrente da ilicitude da prova coligida nos autos. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal instaurada apurar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos fatos narrados na denúncia.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

O "caput" do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas ao comércio e a movimentação substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o objeto jurídico é a saúde pública.

Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/08/2015).

De início, passo a análise dos depoimentos prestado em juízo e demais provas colacionadas ao caderno processual, Vejamos.

A testemunha JOSÉ CARLOS FEITOSA, Policial Militar, ao ser inquirida em juízo, afirmou que "Atendeu a ocorrência. Estávamos em patrulhamento quando um informante ligou, dizendo que o réu estaria vendendo drogas na esquina da creche. Como o réu era pessoa conhecida, fomos abordá-lo. Com ele, em buscas pessoais, somente foram localizados R\$ 30,00 (trinta reais). Ao indagá-lo, o réu confessou que só havia três pedras de crack em sua casa, dentro de um banheiro que estaria em reforma. Fomos até o imóvel e em contato com o senhor Natalino, tio de Natan, houve autorização para a entrada no imóvel. No local, constatamos a existência de um banheiro em reforma, onde havia com caixa com um cano serrado. Em seu interior, achamos as pedras de crack. O réu informou, ainda, que havia outras duas pedras atrás de um cano, que acabaram sendo localizadas. Ele assumiu a propriedade da droga e isentou seu tio de qualquer responsabilidade. Recebemos a informação sobre a atividade do réu por meio do telefonema de um informante, que indicava especificamente o nome de Natan. Tínhamos outras denúncias sobre ele e seu

envolvimento com o tráfico. No momento da abordagem, ele estava parado, sozinho. O local é conhecido como ponto de tráfico e várias prisões já foram realizadas ali. No momento, o réu alegou que os R\$ 30,00 (trinta reais) eram provenientes da venda de drogas e que havia três pedras em sua casa e que o restante já havia sido vendido. No interior da residência, os entorpecentes foram localizados em um banheiro que estava em obras, no interior do imóvel. Tivemos que atravessar a cozinha e uma sala para acessar o local. No imóvel, além de Natan, residiam seu tio e a avó, que estava dormindo no momento das buscas. Tínhamos notícias de que ele havia sido preso anteriormente. Nenhum apetrecho foi localizado no imóvel. Nos deparamos com ele na rua e já o abordamos. Ele estava sentado em uma bicicleta, sozinho. Não vimos ele se aproximar de ninguém. Em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado na posse do réu. A casa de Natan ficava distante cerca de dois quarteirões do local da abordagem, cerca de 200 (duzentos) metros. Ele autorizou a entrada na casa e, posteriormente, o seu tio, que nos atendeu, também, Informei ao tio que ele Natan já nos havia revelado a existência do entorpecente. O tio Natalino também foi conduzido à Delegacia de Polícia”.

Já a testemunha THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA, Policial Militar, reiterou o teor do depoimento de seu companheiro de farda. Disse que “o Subtente Carlos recebeu a denúncia envolvendo o réu. Natan foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico, já tendo ocorrido outras prisões e apreensões naquele lugar. No momento, ele estava na esquina, parado, em cima de uma bicicleta, sem qualquer outra pessoa por perto. O seu tio Natalino também foi apresentado como testemunha na Delegacia de Polícia. Fizemos a apreensão dos entorpecentes somente no banheiro, conforme o réu já havia indicado. No quarto e demais dependência não me recordo se houve algum tipo de busca. Ele já foi preso outras oportunidades com drogas e por furto”.

A testemunha KÁTIA DA SILVA SANTOS, por seu turno, esclareceu que “Natan já foi detido outras vezes. Ele é usuário de drogas, e usa pedra. Natalino é seu irmão. Conversou com ele posteriormente, mas ele não me disse nada sobre ter autorizado a polícia a fazer buscas no interior do imóvel”.

Por fim, ao ser interrogado em juízo, o réu NATAN GOMES DA SILVA afirmou que não são verdadeiras as imputações constantes na denúncia. “Minha mãe havia me dado R\$ 200,00 (duzentos reais), que eu utilizei para comprar 17 (dezesete) porções de crack de um adolescente na esquina. Levei a droga para minha casa, guardei 14 (quatorze) porções em uma cano e outras 03 (três) em outro. Tomei banho, me arrumei, peguei uma pedra, R\$ 30,00 (trinta reais) e fui pra casa da minha namorada, que mora em frente à escola. Bem em frente ao local existe uma mata. Fui até lá fumar a pedra, pois não gosto de usar drogas na frente dos meus familiares. Quando estava voltando, me deparei com os Policiais e acabei sendo abordado, que me pressionaram a entregar. Eles foram até a minha casa, mas não foram autorizados a ingressar em seu interior. Ninguém sabia que eu era usuário de drogas quando de minha abordagem. Eu fico “meio diferente” ao usar as drogas. Não tenho nenhum diagnóstico de doenças. Os Policiais conversaram em tom de ameaça. Fui algemado e levado até em casa “no chiqueirinho”. Foram feitas buscas no banheiro e no meu quarto. Não autorizei a entrada dos policiais no interior de minha residência. Meu tio também não os autorizou. Não estava vendendo drogas e estava somente de passagem pelo local quando fui preso”.

No caso em tela, a despeito da discussão quanto à propriedade e destinação da droga apreendida nos autos (1,39g de cocaína, na forma conhecida como crack), entendo que o réu deve ser absolvido em razão da ilicitude da prova coligida nos autos, decorrente da ausência dos pressupostos para ingresso em seu domicílio.

A teor do disposto no art. 5º, inciso XI. da CF/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,

por determinação judicial.”

Da interpretação conferida pela jurisprudência acerca do deferido dispositivo constitucional, o ingresso no domicílio do réu somente é admitido em três situações: a) Se houvesse autorização judicial para tanto; b) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador; c) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local.

Com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em contrário, entendo que nenhuma das hipóteses encontravam-se configuradas no caso concreto.

Nesse sentido, a ausência de autorização judicial prévia para ingresso no imóvel é incontroversa, já que não consta dos autos qualquer representação pela busca e apreensão no local.

Quanto ao consentimento do morador - tema tratado de forma ainda incipiente pela doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente em razão da falta de especificação legal dos requisitos de sua validade - entendo que tal requisito também não se encontra seguramente demonstrado no caso vertente.

Conforme se extrai dos autos e do relato das próprias testemunhas, o tio do réu, identificado como “Sr. Natalino”, teria franqueado o ingresso dos policiais ao interior do imóvel e autorizado a realização das buscas.

Ocorre que, compulsando os autos, não se verifica qualquer comprovação acerca de tal consentimento ou da forma como ele foi concedido, já que o aludido morador (“Sr. Natalino”) sequer foi ouvido na fase de Inquérito ou arrolado como testemunha na fase judicial - em que pese a informação de que teria sido encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com o réu Natan, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência e do Auto de Prisão em Flagrante.

Registre-se, nesse ponto, que não se trata de desmerecer a honrosa e valorosa atividade desenvolvida pelos Policiais Militares no exercício sua indispensável atividade de vigilância e repressão de ilícitos, ou mesmo de presumir ilicitudes em suas condutas.

O que se pondera é que, no caso concreto, não restou minimamente comprovado a higidez do alegado consentimento conferido por terceiro indivíduo, já que em nenhum momento o “Sr. Natalino” prestou depoimento perante a Autoridade Policial ou foi arrolado como testemunha nos autos, não havendo qualquer outra espécie de declaração ou documentação (escrita ou gravada) que corrobore tal entendimento.

Por fim, quanto a existência de fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no local, rememoro que tal tema já foi objeto de tese de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Na tese firmada ficou assentado que

“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Ocorre que, a partir deste emblemático julgado, distintas interpretações vêm sendo conferidas pelos Tribunais sobre o correto alcance da expressão “fundadas razões”, havendo respeitável posicionamento que entende ser suficiente para o ingresso em domicílio sem mandado judicial o mero fato de tratar-se da ocorrência de crime

permanente (art. 303, CPP).

Contudo, da ratio decidendi do V. Acórdão, é possível extrair que a simples hipótese de ocorrência de flagrante delito em caso de crime permanente, por si só, não justificaria a entrada em domicílio sem o competente mandado, o que correspondia ao entendimento antigo e superado do Supremo:

“A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem a autorização de seu dono, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente. Pretendo demonstrar que essa tese esvazia a inviolabilidade domiciliar, contrariando a interpretação sistemática da própria Constituição e tratados de direitos humanos dos quais o país é signatário. Por isso, proporei evolução do entendimento” [...] A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário”. (grifamos)

Ao longo do seu voto, o i. Relator busca trazer maior racionalidade sobre a problemática.

“A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois. O controle judicial da investigação criminal serve para compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública. Esse controle pode ser a priori – antes da adoção da medida que afeta direitos fundamentais – ou a posteriori – após a adoção da medida. No controle prévio, a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização. No controle a posteriori, a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito [...] Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente”. (grifamos)

E nesse sentido é que a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado, à luz da ratio decidendi do aludido Acórdão, tentando dar concretude ao conceito de “fundadas razões” a fim de evitar se converter em salvo conduto para que a polícia ingresse em qualquer residência à procura de drogas.

O voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz no RHC 83501/SP bem esclarece a situação:

“Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um “terceiro neutro e desinteressado”) só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.”

No caso em tela, pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese a aparente boa-fé dos Policiais Militares condutores do flagrante, entendo que não havia elementos concretos que justificassem o ingresso em domicílio sem a prévia

autorização judicial.

Frise-se, nesse sentido, que o réu foi abordado em meio a uma rua próxima de sua residência, enquanto estava “sozinho”, “em uma bicicleta”, “sem qualquer outra pessoa por perto” e sem estabelecer contato com terceiros. Ademais, em buscas pessoais, “nada de ilícito foi encontrado” em sua posse, apenas R\$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Diante de tais dados concretos, entendo que o imediato deslocamento para a residência do réu e a realização de buscas por entorpecentes em seu interior não se encontravam aparadas em “fundadas razões”, seja em razão da ausência de prova segura quanto ao consentimento válido e inequívoco do morador, seja em virtude de o ingresso ter se baseado apenas em denúncias anônimas prévias e uma pouco crível declaração auto-incriminadora do acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no seguinte sentido:

“PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (Resp 1871856/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifamos).

Assim, cancelar o ingresso em domicílio de um indivíduo que foi abordado sozinho, em meio a rua, sem qualquer constatação de prática de ilícito após buscas pessoais e sem o preenchimento dos pressupostos já mencionados no bojo desta fundamentação, permitiria o esvaziamento da garantia constitucional consagrada no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, reduzindo-a a inadmissíveis “ingressos para averiguação”.

Eis a razão pela qual, as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – art. 157, §1º, CPP), o que impõe a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia para ABSOLVER O RÉU NATAN GOMES DA SILVA da imputação da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, CPP.

REVOGO eventuais medidas cautelares fixadas.

Expeçam-se os ofícios, comunicações e certidões de honorários advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paraguacu Paulista, 10 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA